

1500342-66.2021.8.26.0691

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Comarca: Buri

Foro: Foro de Buri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... tóxicos ilícitos.

(ii) do crime de associação para o tráfico de drogas

Em que pese a prova robusta em relação ao crime de tráfico de drogas, quanto à imputação pela associação criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.340/2006, inexistente, nos autos, prova de que os réus mantinham associação permanente, estável e duradoura visando a prática do tráfico de drogas.

Isto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buri

Foro de Buri

Vara Única

Rua Carlos Alberto Pereira Jr, 549, Buri - SP - cep 18290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500342-66.2021.8.26.0691 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500342-66.2021.8.26.0691

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA JENIFER DA SILVA INACIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GILVANA MASTRANDÉA DE SOUZA

Vistos.

I - RELATÓRIO

JOSÉ JORGE PEREIRA e AMANDA JENIFER DA SILVA INÁCIO foram denunciados e estão sendo processados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei de Drogas (Lei n. 11343/2006), c.c. o artigo 61, II, "j" (em ocasião de qualquer calamidade pública), e na forma do artigo 69, caput, estes também do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia;

"desde data incerta até o dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 11h50, na Rodovia SP 189, altura do Km 23, próximo da Fazenda Aliança II, nesta cidade e Comarca de Buri, JOSÉ JORGE PEREIRA e AMANDA JENIFER DA SILVA INÁCIO, qualificados respectivamente a fls. 06 e 08, em ocasião de calamidade pública, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), inclusive o abaixo descrito. desde data incerta até o dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 11h50, na Rodovia SP 189, altura do Km 23, próximo da Fazenda Aliança II, nesta cidade e Comarca de Buri:

Consta, ainda, dos inclusos autos de boletim de ocorrência que, no dia 02 de

dezembro de 2021, por volta das 11h50, na Rodovia SP 189, altura do Km 23, próximo da Fazenda Aliança II, nesta cidade e Comarca de Buri, JOSÉ JORGE PEREIRA e AMANDA JENIFER DA SILVA INÁCIO, qualificados respectivamente a fls. 06 e 08, em ocasião de calamidade pública, e agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e comunhão de esforços, traziam consigo e transportavam, para entrega a terceiros, 02 (duas) pedras de cocaína, sob a forma de "crack, pesando 177,70g (cento e setenta e sete gramas e setenta centigramas) de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se infere do auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, do laudo de constatação a fls. 27/30 e do laudo químico-oxicológico a ser oportunamente juntado.

(...)

Segundo se apurou, os denunciados dedicavam ao tráfico de entorpecentes. Para tanto, em associação que se iniciou em data incerta, transportavam os entorpecentes.

Com efeito, guardas municipais, após "denúncia" de tráfico de drogas, passaram a acompanhar o veículo HB20, de cor cinza, e placas GCJ7D85, tendo solicitado também o apoio da Polícia Militar; os denunciados, ocupantes do veículo, após constatarem a presença dos agentes de segurança, dispensaram um objeto branco pelo vidro do passageiro e pararam o veículo. Em abordagem e busca pessoal, os agentes encontraram com JOSÉ a quantia de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em dinheiro e um aparelho de telefone celular; com AMANDA, encontraram o valor de R\$ 100,00 (cem reais) em dinheiro.

Em averiguação no local onde a passageira (AMANDA) arremessou o objeto, encontraram um par de meia branca e em seu interior duas porções de "crack", pesando quase duzentas gramas"

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 128/131). Na mesma decisão, foi autorizado à autoridade policial a pesquisa de informações existentes na memória do celular apreendido.

Os acusados foram citados (fls. 191 e 193) e apresentaram defesa prévia (fls. 206/211).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e as mesmas testemunhas arroladas pela Defesa. Ao final, os réus foram interrogados.

Sobreveio informação de apuração do crime de falsidade ideológica nos autos nº 1500070-38.2022.8.26.0691 (fls. 259).

Em sede de alegações finais por memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, e a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, aplicação da atenuante da confissão para Amanda e pena base no mínimo legal. .

Folha de Antecedentes da ré (fls. 78/ 82 e 180/185) e Certidão do Cartório Distribuidor criminal (fls. 75/77).

Folha de antecedentes do réu em nome de José Jorge Pereira (fls. 72/74) e Certidão do Cartório distribuidor criminal (fls. 253/255); e Certidão do Cartório Distribuidor em nome de José Jorge de Campos Júnior (fls. 256/258).

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

II – PRELIMINARES

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

III – MÉRITO

(i) Do crime de tráfico de drogas:

Finalizada a instrução penal, verifica-se que a prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal dos réus pela prática do crime de

tráfico de drogas.

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: boletim de ocorrência (fls. 14/19), auto de apreensão (fls. 20/21), auto de constatação do entorpecente apreendido (fls. 27/30), laudo do celular (fls. 242/246), laudo do carro (fls. 247/252), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 267/270), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, induvidosa sua atribuição aos réus, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em solo policial, os acusados exerceram o direito de se manifestarem apenas em juízo.

Em Juízo, a ré AMANDA disse que estava passando por dificuldade financeira e então uma pessoa da cidade onde mora disse que um pessoal de Tatuí estava precisando de uma menina que retirasse uma droga em Buri e que eles pagariam mil reais. Disse que inventou uma história para o José para ir até Buri, encontrou com a pessoa, pegou e voltou. Iam voltar por Campina do Monte Alegre porque disse que queria passar por ali, porque estava com medo do pedágio. Conhecia o José da cidade, ele tinha amizade com o marido, pai do filho. Combinou com o réu pessoalmente da busca das drogas, foi perto da casa da interrogada. Estava pensando como iria, pensou em ir de ônibus, não sabia como, ele estava com este carro, ele passou ali e falou para ele. Não lembra exatamente o que "inventou" para ele ir até lá. Pagaria para o réu, mas não combinou valor. É "longinho" Cesário Lange de Buri, durou aproximadamente 1h e pouco para mais. Desceu do carro, foi a pé, disse para ele que já voltava e encontrou um cara em uma praça. Encontrou ele ali, reconheceu ele pela roupa e pegou a droga. Pegou as pedras, guardou com a depoente, passou neste hotel, deixou ele perto deste hotel. As drogas estavam guardadas com a interrogada. As duas pedras tinha colocado dentro do tênis. Quando viu a viatura colocou dentro da meia e jogou pela janela. Colocou a droga no meio do tênis e entrou no carro assim. O José não desconfiou de nada. Não lembra qual foi a história que inventou para ele. Falou informalmente aos policiais que a droga era realmente da interrogada. Não sabe se o José tem vínculo com associação criminosa. Não é alguém muito próximo dele, mas conversava com ele e acreditou que ele levaria. Não conhecia os policiais que prenderam a interrogada. Ia receber o dinheiro na hora que entregasse as drogas. Foi a interrogada que pagou a gasolina e pedágio. Não foi no mesmo dia da viagem que conversou com o José, foi um ou dois dias antes. Não tinha celular do José.

Em Juízo, o réu JOSÉ JORGE disse que gosta da Amanda e ela pediu para levar até a cidade de Buri, mas não falou o que ia fazer, falou que ia "resolver uns negócios dela". Emprestou um carro do tio. Levou ela, ficou por volta da cidade em 1h e quando saíram a viatura da guarda começou a ir atrás e ela jogou algo pela janela. Abordaram e vieram falando que era do PCC, da qual não faz parte. Não lembra bem o dia, foi a Amanda que pediu para levar na semana lá, na cidade. Foi pessoalmente e por telefone que foi combinado. Foi em frente à casa dela e no telefone celular. Não lembra quantos dias depois veio para Buri. Foi depois de aproximadamente 1 semana que levou ela. Não sabe falar ao certo. Fez isso por amor, porque é apaixonado por ela, mas ela falou que não era de errado. Foi o interrogado quem pagou pedágio e gasolina. Deixou ela em uma rua próximo em uma praça, parou o carro e deixou ela ali. Ela voltou depois de 40min, 1 hora. Perguntou para ela que estava tudo certo. Ela estava com uma bolsa. A droga estava guardada dentro da bolsa dela. Só viu ela mexendo em uma sacola, olhou no vidro retrovisor, a polícia estava perto e ela jogou. Ela pediu desculpa. Não conhecia os policiais que abordaram. Não sabe porque eles falaram que a denúncia anônima apontava ele como autor do crime. Já tinha conhecimento que a AMANDA foi presa por tráfico. Alguns momentos pensou que pudesse ser droga, alguns momentos não. Foi a PM quem chegou apontando que era do PCC. Viu uma sacola na mão dela. Não ficou reparando nela.

A testemunha FABIO ROGERIO RODRIGUES DE MEDEIROS, policial militar, afirmou que receberam denúncia de que um veículo HB20 (com a informação da placa do referido

veículo) estaria vindo do município de Buri e iria passar pelo município do declarante. Saíram em patrulhamento e na rodovia cruzaram com o veículo e para fazer o retorno para acompanhá-lo, o veículo notou o veículo retornando e aumentou a velocidade. Quando o veículo percebeu a viatura da PM, ele entrou na estrada de terra e pouco antes de entrar nesta estrada visualizaram pelo passageiro sendo jogado um objeto branco pela janela. Depois o carro parou. Em abordagem, estavam o Jorge e a ré e após busca pessoal nada foi encontrado, mas retornaram ao local onde foi jogado alguma coisa, encontraram uma meia com substância dentro aparentando ser "crack". A ré assumiu que a droga era dela e que ela jogou a droga. Os dois foram consultados via Copom, os dois possuíam condenação por tráfico. Não sabe quanto tempo antes de acessar a estrada de terra ele jogou, mas foi logo que o carro entrou pela estrada de terra. Quem arremessou o objeto foi pelo vidro do passageiro, mas não foi possível precisar se foi o passageiro ou o motorista. O Jorge falou que não sabia que a mulher estava com as droga. Disse que tinham saído para se divertir e o veículo que estava na posse dele era de um tio e não sabia da procedência. Todas as drogas estavam dentro da meia e, inclusive, a ré estava de tênis e sem meia. Dá para entender que durante o acompanhamento ela colocou as droga na meia e jogou pela janela. Pela denúncia que chegou através de Copom, disse que quem estaria no interior do veículo seria o Jorge e que ele seria da facção criminosa. Pelo depoente não foi feita diligência. Em conversa com equipe que ele falou isso. Não se recorda se foi apreendido dinheiro, e se não se recorda foi apreendido um celular. Foi uma denúncia que passou inclusive a placa do veículo. A testemunha WILLIAN CAMPOS DE LIMA, guarda municipal, disse que estavam de plantão e foram informados pela PM que haviam recebido denúncia via Copom de que um veículo Hyundai estaria vindo de Buri para Campina do Monte Alegre com certa quantidade de entorpecente. Foram em apoio e no contra-fluxo avistaram o veículo, fizeram o retorno, fizeram breve acompanhamento, deram ciência aos PM que foram de encontro e quando o veículo entrou em uma estrada de terra foi avistada a passageira, a AMANDA, jogar algo branco do lado de fora do veículo. Eles foram abordados, nada de ilícito foi encontrado, e ao retornarem para ver o que ela havia jogado foi encontrada substância análoga ao crack. Foi feita também a vistoria no veículo e alguns sinais de identificação estavam alterados. Os PM optaram por chamar um mecânico e ele constatou que o veículo, salvo engano, era produto de roubo. Eles foram conduzidos ao DP e registrado o flagrante. O Jorge dizia que não tinha conhecimento da droga, mas a notícia tratava somente dele. O alvo da denúncia era ele, inclusive o denunciante que passou para o COPOM dizia que ele fazia parte de facção criminosa. A AMANDA confirmou que a droga era dele e inclusive confirmou que a meia que estava acondicionado o entorpecente era dela.

Verifica-se, portanto, que finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia.

A acusada AMANDA confessou que estava transportando as drogas apreendidas, tentou, todavia, isentar o comparsa JOSÉ da responsabilidade criminal. A negativa, todavia, não convenceu.

Primeiro porque as versões dos réus em seus interrogatórios judiciais apresentam várias divergências relevantes. Senão vejamos: (i) enquanto AMANDA afirmou que convidou JOSÉ para levá-la até Buri presencialmente em frente à sua casa, JOSÉ disse que foi tanto pessoalmente como por telefone; (ii) enquanto AMANDA afirmou que ela foi quem pagou o pedágio e gasolina do carro, JOSÉ narrou que foi ele; (iii) enquanto AMANDA alegou que foi buscar a droga em uma praça em Buri e que JOSÉ parou o carro próximo a um hotel, JOSÉ afirmou que parou em uma rua próxima da praça, nada dizendo sobre o suposto hotel; (iv) enquanto AMANDA disse que estava escondendo as duas pedras de "crack" (pesando no total 177,7g) dentro de seu tênis no automóvel, JOSÉ alegou que as drogas estavam guardadas dentro da bolsa da ré. Enfim, as contradições não deixam dúvidas de que os réus mentiram em juízo.

Segundo porque a narrativa da acusada AMANDA de que entrou no carro com as drogas escondidas dentro de seu tênis – e que por isto JOSÉ não teria visualizado – é absolutamente fantasiosa. A foto de fl. 29 exhibe a enorme quantidade de "crack" apreendido, sendo duas pedras de grande proporção, impossível de serem colocadas dentro de um tênis calçado. Também não é crível a alegação de AMANDA de que não se

recorda do que disse para JOSÉ para convencê-lo a vir até Buri, cidade distante mais de 1h de Cesário Lange. A alegação de JOSÉ de que fez isto por "amor", porque estava apaixonado também não é digna de qualquer credibilidade, sobretudo porque a própria acusada alegou que JOSÉ era apenas um "conhecido" seu, amigo do marido dela. A alegação, portanto, está absolutamente isolada nos autos.

Curioso apontar que o acusado JOSÉ, ao ser questionado sobre ter conhecimento que AMANDA já havia sido condenada por tráfico, afirmou que tinha ciência e que em alguns momentos ficou desconfiada de que ela poderia vir buscar drogas na cidade, ou seja, ainda que se acredite em sua versão inverossímil, fica evidente que agiu com dolo eventual, assumindo o risco do transporte ilícito dos entorpecentes.

Terceiro porque conforme narrado pelo policial militar e guarda municipal responsáveis pela prisão dos réus, a denúncia anônima recebida apontava o acusado JOSÉ como integrante de facção criminosa e como sendo a pessoa que estava transportando as drogas, inexistindo motivos para que pudessem querer mentir para prejudicar falsamente um inocente.

Com efeito, observa-se que os testemunhos dos funcionários da polícia são harmônicos e descrevem os fatos com clareza, sendo que não há nenhum elemento capaz de colocar tais declarações em dúvida. Essas palavras, produzidas por pessoas isentas, que não tinham razões para prejudicar o acusado – sobretudo porque nada foi levantado neste sentido e porque não o conheciam anteriormente –, são mais que suficientes para embasar a condenação, pois, consoante iterativa jurisprudência, nada impede que a condenação se dê com base nas palavras dos policiais.

Sobre o tema, já decidiu Col. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL.

CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017); "...Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)." (HC 373.394/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Destaca-se, ainda, que o laudo pericial realizado no conteúdo do aparelho celular apreendido dentro do automóvel identificou conversas que abrangem negociação de drogas (fls. 245/246):

"Interlocutor A - É isso, calma aí. Calma aí. Ou, mas arruma um baseado pra mim viado?

Interlocutor B - Nem tem maconha aqui fio. Maconha não tenho mais. Vendi o único que tinha. Eu falei pra você ir ontem lá buscar e você não foi viado. Maconha minha acabou mano. Eu vou lá em Sorocaba pegar um cara lá pra trazer aqui na condução que ele é prova dos cara. Entendeu mano? (inteligível) Dos irmão lá nos predinho. Lá no Votorantim eu vou. Que que acontece, eu vou só no (inteligível) entregar essa parada que mandei foto pra você aí pra muié lá mano. Se tiver mais já põe junto se quiser, que a muié já paga tudo eu já. Como não vai dar pra eu entregar o dinheiro pra você hoje, que eu vou chegar papo reto. Só em casa, só amanhã de noite, mano". No mais, sobreleva mencionar que o delito de tráfico de drogas está descrito em tipo penal misto alternativo, de modo que, à caracterização do crime, basta a

prática de apenas uma das ações típicas. O efeito prático disso é que, para que se configure o tráfico, não é imprescindível que o infrator seja flagrado vendendo a mercadoria proibida, bastando a concretização de qualquer uma das dezoito condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre eles "guardar e transportar", com o intuito de venda.

Por fim, importante destacar que ambos acusados são reincidentes pela prática de tráfico, sendo que o acusado JOSÉ JORGE estava em livramento condicional de uma dessas condenações, o que comprova a habitualidade delitiva do réu especificamente com a venda de tóxicos ilícitos.

(ii) do crime de associação para o tráfico de drogas

Em que pese a prova robusta em relação ao crime de tráfico de drogas, quanto à imputação pela associação criminosa prevista no art. 35 da Lei 11.340/2006, inexistente, nos autos, prova de que os réus mantinham associação permanente, estável e duradoura visando a prática do tráfico de drogas.

Isto porque, não obstante o fato de terem encontrado a droga sob a posse de ambos os réus, não há prova do vínculo associativo, visto que não foram angariados elementos que pudessem concluir para este fim, como interceptações telefônicas prévias, campanhas, ou mesmo localização dentro da residência dos réus de drogas, aparatos para sua fabricação ou anotações.

Assim, não há nos autos elementos probantes indicativos do vínculo associativo duradouro entre os acusados caracterizado pela estabilidade e permanência, com o fim de praticarem a narcotraficância, tratando-se, quando muito, de associação eventual ou ocasional, ou mero concurso de pessoas.

Não há dados suficientes que apontem a presença da intenção associativa dos réus com a finalidade de traficar drogas. Eventual coincidência de interesses e colaboração entre eles para o êxito do comércio ilícito não indicam a presença do crime imputado na inicial.

Não por outro motivo o Ministério Público solicitou a absolvição dos acusados em relação a este delito.

Com isso, atentando-se ao princípio do "in dubio pro reo", é caso de absolvição dos acusados da prática do crime previsto no art. 35, "caput" da Lei 11343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

(i) do réu José Jorge

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu ostenta três condenações específicas por tráfico de drogas, de modo que utilizo duas delas como Maus Antecedentes - processo n. 0007222-09.2005.8.26.0272 (data do fato 27/11/2005 e data do trânsito em julgado para a defesa/extinção da pena 30/11/2009, fls. 254) e processo n. 0008502-84.2009.8.26.0624 (data do fato 25/08/2009 e data do trânsito em julgado para a defesa/extinção da pena 20/09/2010, fls. 257), e outra como reincidência na segunda fase da dosimetria penal. Importante destacar que o acusado, ao que consta, utilizava dois nomes distintos para se identificar – o que está sendo melhor apurado no termo circunstanciado nº 1500070-38.2022.8.26.069 -, todavia, ele mesmo admitiu ter sido condenado três vezes por tráfico nos processos mencionados, assim, não restam dúvidas de que o réu foi condenado nos processos que ora se aponta como Maus Antecedentes e reincidência. c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram anormais, porque o crime foi praticado entre Municípios (Buri-Cesário Lange, distantes aproximadamente 150km), a demonstrar maior possibilidade de disseminação das drogas e maior reprovabilidade da conduta. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. i) Natureza e quantidade da substância: a droga encontrada com o acusado (crack) é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando considerável grau de dependência, além disto a quantidade foi expressiva (177

gramas), o que justifica a exasperação da pena nesta fase (HC 413.928/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 11/10/2017).

Assim, considerando a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima apontadas, e considerando que os maus antecedentes envolvem a prática do mesmo crime (tráfico), aumento a pena nesta fase em 1/3 (um terço), fixando em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, incabível a incidência da agravante do art. 61, II, "j", do CP, porque os fatos em apreço não guardam qualquer relação com o estado de calamidade pública decretado pela pandemia do coronavírus, não tendo o acusado se aproveitado desse contexto para a prática criminosa. Este vem sendo o entendimento do E. TJ-SP: "FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA A INCRIMINAR OS RÉUS - QUALIFICADORAS COMPROVADAS NOS AUTOS - MAJORANTE BEM DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - PENAS COMPORTAM ATENUAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'j', CP - REGIME INICIAL MANTIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE" (TJSP; Apelação Criminal 1521477-05.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021). Por outro lado, reconheço a agravante da reincidência específica (autos n. 0004586-37.2012.8.26.0624 - data do fato 04/04/2012 e trânsito em julgado para a defesa 16/04/2015, fls. 256), motivo pelo qual aumento a pena do réu nesta fase em 1/5 (um quinto), resultando na pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Não há que se falar em aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência específica do réu.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49). (ii) da ré Amanda Jenifer da Silva Inacio

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: foi normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: a ré possui uma condenação que será valorada na segunda fase da dosimetria penal réu não ostenta maus antecedentes. Ademais, relembro que ações penais e inquéritos penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes (Súmula nº 444, do STJ). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: foram anormais, porque o crime foi praticado entre Municípios (Buri-Cesário Lange, distantes aproximadamente 150km), a demonstrar maior possibilidade de disseminação das drogas e maior reprovabilidade da conduta. g) Consequências do crime: embora reprováveis, também foram normais. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações. i) Natureza e quantidade da substância: a droga encontrada com a acusada (crack) é extremamente nociva à saúde pública, bem como detém alto poder destrutivo, causando considerável grau de dependência, além disto a quantidade foi expressiva (177 gramas), o que justifica a exasperação da pena nesta fase (HC 413.928/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 11/10/2017).

Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, aumento a pena nesta fase em 1/5 (um quinto), fixando em 6 anos e pagamento de 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, incabível a incidência da agravante do art. 61, II, "j", do CP, porque os fatos em apreço não guardam qualquer relação com o

estado de calamidade pública decretado pela pandemia do coronavírus, não tendo o acusado se aproveitado desse contexto para a prática criminosa. Este vem sendo o entendimento do E. TJ-SP: "FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA ROBUSTA A INCRIMINAR OS RÉUS - QUALIFICADORAS COMPROVADAS NOS AUTOS - MAJORANTE BEM DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - PENAS COMPORTAM ATENUAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'j', CP - REGIME INICIAL MANTIDO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE" (TJSP; Apelação Criminal 1521477-05.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021).

Considerando a confissão, ainda que parcial, mas que foi utilizada como convencimento neste julgamento (súmula 545, do STJ), compenso com a agravante da reincidência (0001038-28.2017.8.26.0624 - data do fato 01/01/2017 e trânsito em julgado para a defesa 05/08/2019, fl. 76), efetuo a compensação entre elas.

Na terceira fase da dosimetria penal, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Não há que se falar em aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência da ré.

Assim, estabeleço a pena final da ré em 6 (seis) anos e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

V - DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PRD OU SURSIS (i) do réu José Jorge

Diante da reincidência específica do acusado, do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena e que o réu é reincidente específica pelo crime de tráfico de drogas. Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

(ii) da ré Amanda Jenifer da Silva Inacio

Diante da reincidência da acusada, do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e da existência de circunstâncias judiciais negativas, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'a', do Código Penal). A propósito, embora a acusada não tenha sido condenada definitivamente nos autos do processo nº 0003956-50.2015.8.26.0470 pela prática de tráfico de drogas, verifica-se que já existe sentença condenatória confirmada pelo Tribunal de Justiça, a evidenciar que a fixação de regime mais brando não se mostra suficiente para repressão e punição pela prática, novamente, do mesmo delito.

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista o quantum da pena e que a ré é reincidente em crime doloso.

Também não verifico possível a suspensão condicional da pena, diante da ausência dos requisitos do art. 77, do Código Penal.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

Não há bens apreendidos nos autos para serem destruídos.

Determinar que seja efetuada a destruição das drogas caso tal medida não tenha sido tomada e declaro a perda dos valores e bens apreendidos em favor da União;

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo

das Execuções. A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido: "Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei).

VII - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para:

(i) condenar JOSÉ JORGE PEREIRA à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 799 (setecentos e noventa e nove) dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e para absolvê-lo da prática do crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

(ii) condenar a ré AMANDA JENIFER DA SILVA INÁCIO à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e para absolvê-la da prática do crime do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, à luz da condenação que ora se impõe, bem como do fato de terem permanecidos presos durante o curso do processo. Além disso, não se verifica qualquer alteração no cenário levado em consideração no momento da decretação da prisão preventiva (fls. 83/88), de modo que persistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Saliento que o acusado JOSÉ JORGE possui três condenações definitivas pela prática do mesmo crime (tráfico de drogas), assim como AMANDA também possui condenação, ainda pendente de trânsito em julgado, pelo mesmo delito, a evidenciar profundo envolvimento com a criminalidade pelos réus e necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Assim, não permito que recorram em liberdade.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos moldes do art. 804 do Código de Processo Penal, observados os benefícios da justiça gratuita.

Arbitro honorários no máximo da tabela ao advogado dativo nomeado para defesa dos interesses do réu.

Após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lancem o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. 4) Oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se o caso. 5) Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, se o caso. 6) Expeça-se certidão de honorários.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Ciência ao MP.

P.I.C.

Buri, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA